OBJECTIF BARREAU

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

DROIT ADMINISTRATIF

. L'administration poursuit une finalité d'intérêt général. Son action prend notamment la forme de missions de service public et de mesures de police administrative, destinées à prévenir ou à faire cesser les troubles à l'ordre public. L'administration assure notamment des missions de service public, parmi lesquelles figure la police administrative. Un service public est une activité d'intérêt général assurée par une personne publique ou confiée à une personne privée dans des conditions permettant de la regarder comme chargée d'une mission de service public. Lorsqu'une personne privée exerce l'activité, la qualification de service public dépend notamment de la volonté de la personne publique de lui confier cette mission, des conditions d'organisation et de contrôle de l'activité et, le cas échéant, de l'existence de prérogatives de puissance publique. Ces dernières ne sont pas toujours indispensables à la qualification de service public (CE, sect., 22 février 2007, APREI)

La police administrative constitue un service public administratif et non un service public industriel et commercial. Cette qualification tient avant tout à son objet : la protection de l'ordre public, qui implique l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il n'est donc pas nécessaire de présenter son financement ou son mode de gestion comme des conditions systématiques de cette qualification. Les critères de l'objet, des ressources et des modalités de fonctionnement servent principalement à distinguer les SPA des SPIC lorsque la nature du service est incertaine.

Tout d'abord, en exerçant ses pouvoirs détenus en matière de police administrative, l'administration est amenée à adopter des actes juridiques qui peuvent restreindre les droits et libertés fondamentaux. Il convient par conséquent de revoir les fondamentaux en la matière (I).

Ensuite, le juge administratif au travers du contrôle de l'action administrative est appelé à protéger les droits et libertés fondamentaux. Il convient alors dans un second temps, de mettre en exergue les principes fondamentaux du contentieux administratif (II).

I. LA POLICE ADMINISTRATIVE

À l'image de toute étude portant sur une notion juridique, la définition de la police administrative (A) est un préalable nécessaire à l'analyse de son régime (B).

A. L'IDENTIFICATION

La distinction entre police administrative et police judiciaire permet de déterminer le droit applicable et de désigner, de ce fait, le juge compétent. En effet, les litiges engendrés par la police administrative relèvent, en principe, du droit administratif et de la compétence du juge administratif, contrairement à ceux engendrés par la police judiciaire (1).

La définition de la police administrative se fait au travers de son but, à savoir, le maintien de l'ordre public (2). Ce dernier est l'élément essentiel de la définition de la police administrative.

Les autorités administratives qui détiennent des pouvoirs de police administrative sont diverses et pour les déterminer, il convient de distinguer la police administrative générale des polices administratives spéciales (3).

1. La distinction entre police administrative et police judiciaire

La police administrative est une activité qui vise à assurer le **maintien de l'ordre public**, sans tendre à la recherche ou à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée. Ainsi, la distinction entre police administrative et police judiciaire ne se situe pas uniquement dans la différence entre prévention et répression. Certes, la police administrative tend à avoir un caractère préventif, mais elle permet parfois de faire cesser des troubles existants. De même, la police judiciaire peut avoir un caractère préventif, même si elle est surtout répressive. En réalité, le critère de distinction est le but de l'opération, apprécié au regard des circonstances dans lesquelles elle est conduite. Lorsque l'opération tend à constater une infraction déterminée, à en rassembler les preuves ou à en

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

rechercher les auteurs, elle relève de la police judiciaire. Lorsqu'elle vise à prévenir ou à faire cesser un trouble à l'ordre public, indépendamment de la recherche des auteurs d'une infraction déterminée, elle relève de la police administrative. La qualification dépend donc de la finalité de l'opération et non de la qualité de l'agent qui l'accomplit : un même agent peut exercer successivement des missions de police administrative et de police judiciaire. Cette distinction finaliste est illustrée par deux décisions (CE section, 11 mai 1951 Consorts Baud où il a été décidé qu' une opération destinée à rechercher les auteurs d'une infraction déterminée relève de la police judiciaire et TC 7 juin 1951 Dame Noualek où le juge administratif a estimé qu' une opération de surveillance destinée au maintien de l'ordre relève de la police administrative). On voit donc que la qualification dépend de l'objectif poursuivi par l'opération. Une même intervention peut changer de nature au cours de son déroulement. Une opération initialement destinée à prévenir un trouble à l'ordre public peut devenir une opération de police judiciaire lorsque les agents entreprennent de constater une infraction déterminée, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs. Il convient alors d'identifier la finalité de l'opération au moment du fait à l'origine du litige, afin de déterminer le régime juridique et le juge compétent.

.

2. Le but de la police administrative

Le but de la police administrative est donc le maintien de l'ordre public. Ce dernier comprend plusieurs éléments. De l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales se dégagent trois composantes principales de l'ordre public : la **sécurité publique**, la **tranquillité publique** et la **salubrité publique**. Il s'agit des **buts primaires** de la police administrative.

À ces composantes traditionnelles s'ajoutent des considérations d'ordre public dites immatérielles, dont le régime doit être distingué. La moralité publique peut justifier une mesure de police administrative lorsque des circonstances locales particulières le justifient. Le Conseil d'État l'a notamment admis à propos de l'interdiction de la projection d'un film (CE, sect., 18 décembre 1959, Société Les Films Lutetia). Le respect de la dignité de la personne humaine constitue, quant à lui, une composante de l'ordre public à part entière. Dans l'arrêt CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, relatif à une attraction de "lancer de nain", le Conseil d'État a admis que le maire puisse interdire une attraction portant atteinte à la dignité humaine, même en l'absence de circonstances locales particulières. Il faut donc éviter de présenter la moralité publique et la dignité humaine comme deux composantes soumises aux mêmes conditions d'intervention

.

3. Les autorités de police administrative

La police administrative se divise en **police administrative générale** et **police administrative spéciale**.

Les mesures de police générale visent la protection de l'ordre public sur un territoire donné, tandis que la police spéciale a, en revanche, un champ plus spécifique (police de la navigation aérienne, police de la chasse, police de l'environnement, etc.).

Les principales autorités de police administrative générale sont :

1. Le Premier ministre : il dispose, à l'échelle nationale, d'un pouvoir réglementaire de police générale, reconnu par l'arrêt du CE rendu en date du 8 août 1919 dit Labonne, et exercé aujourd'hui dans le cadre de ses compétences constitutionnelles.
2. Le maire : il est chargé de la police municipale et du maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de la commune (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT).
3. Le préfet de département : il dispose notamment de pouvoirs de police générale à l'échelle départementale dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du CGCT, ainsi que de certains pouvoirs de substitution au maire.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le président du conseil départemental doit être distingué de ces autorités : il exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, notamment en matière de circulation, sous réserve des compétences du maire et du préfet (article L. 3221-4 du CGCT). Il ne dispose pas, à ce titre, d'un pouvoir général de police administrative comparable à celui du maire.

Lorsque plusieurs autorités de police sont compétentes, il faut rechercher si une autorité locale peut renforcer une mesure prise à un niveau territorial supérieur. En principe, l'autorité locale peut adopter une mesure plus rigoureuse lorsque des circonstances locales le justifient (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains). A noter que lorsqu'une police spéciale a été confiée par les textes à une autorité déterminée, les pouvoirs de police générale ne peuvent pas nécessairement être utilisés pour intervenir dans le même domaine : il faut vérifier les règles propres à la police spéciale concernée.

B. LE CONTRÔLE

Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours contre une mesure de police, il s'interrogera sur sa **proportionnalité**. Cela étant, on doit distinguer les périodes normales (1) des périodes exceptionnelles (2), car dans ce dernier cas, l'autorité administrative peut légalement prendre des mesures de police qui seraient jugées illégales en période normale. Il faut simplement garder à l'esprit que les circonstances exceptionnelles n'excluent pas le contrôle du juge.

1. En période normale

Le contrôle du pouvoir de police résulte d'un compromis entre la **nécessité de maintenir l'ordre public**, et la **nécessité de ne pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux**.

Le juge administratif contrôle la légalité des mesures de police, notamment leurs motifs, leur finalité et l'intensité des restrictions qu'elles apportent aux libertés. Une mesure de police restrictive de liberté doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de maintien de l'ordre public poursuivi. Le juge vérifie notamment que l'autorité de police ne pouvait pas atteindre cet objectif par une mesure moins contraignante. Ce contrôle est illustré par l'arrêt CE 19 mai 1933 dit Benjamin : une interdiction de réunion ne peut être légalement prononcée lorsque des mesures moins restrictives permettraient de prévenir les troubles redoutés. Le juge censure également les interdictions générales ou absolues qui excèdent ce qu'exige le maintien de l'ordre public. L'arrêt du CE Ass 22 juin 1951 dit Daudignac montre à ce titre les limites du pouvoir de police lorsqu'une autorité soumet l'exercice d'une activité à une autorisation préalable sans y être habilitée.

2. En période exceptionnelle

Le contrôle exercé en période exceptionnelle est plus favorable à l'administration. En effet, le droit français admet, dans des situations exceptionnelles, le **renforcement des pouvoirs des autorités administratives** et, corrélativement, la **restriction des droits et libertés fondamentaux**. En période de crise, les pouvoirs de l'administration peuvent être renforcés et certaines restrictions aux libertés peuvent être admises alors qu'elles ne le seraient pas dans des circonstances ordinaires. L'administration demeure toutefois soumise au droit et au contrôle du juge, qui tient compte de la gravité de la situation et de la nécessité des mesures prises. Il convient de distinguer les régimes exceptionnels prévus par les textes (l'article 16 de la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence) de la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles. Selon cette théorie, illustrée par les arrêts du CE du 28 juin 1918 dit Heyriès et du 28 février 1919 dit Dames Dol et Laurent, des circonstances d'une gravité exceptionnelle peuvent justifier un assouplissement temporaire des règles normalement applicables à l'administration, dans la mesure nécessaire pour faire face à la crise et sous le contrôle du juge.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'état d'urgence sanitaire, instauré en 2020, doit être présenté séparément comme un régime historique : ses dispositions spécifiques ont cessé de s'appliquer le 1er août 2022. On envisagera donc les quatre hypothèses : la mise en œuvre de **l'article 16 de la Constitution** (a), la déclaration de l'état de siège (b), de l'état d'urgence (c) et de l'état d'urgence sanitaire (d).

a) L'article 16 de la Constitution

Aux termes de **l'article 16 de la Constitution**, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

L'article 16 confère au Président de la République des pouvoirs exceptionnels lui permettant de prendre les mesures exigées par la crise, y compris des mesures susceptibles de restreindre l'exercice de certaines libertés. Ces pouvoirs ne constituent toutefois pas une autorisation générale de suspendre sans limite les droits fondamentaux : les mesures doivent répondre aux exigences posées par l'article 16. .

Toutefois, les mesures qu'il prend doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, après trente jours d'exercice de ces pouvoirs, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'une des assemblées ou par soixante députés ou soixante sénateurs afin de vérifier si les conditions de l'article 16 demeurent réunies. Il procède de plein droit à cet examen au terme de soixante jours, puis à tout moment au-delà.

A bien noter que le recours à l'article 16 est de la compétence exclusive du chef de l'Etat puisqu'il l'exerce sans la signature du Premier ministre et des ministres.

b) L'état de siège

Il s'agit d'un régime exceptionnel de police décrété en conseil des ministres en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée (**article 36 de la Constitution**). Sa déclaration a pour conséquence **l'attribution à l'autorité militaire de certains pouvoirs exorbitants.** L'état de siège est régi par l'article 36 de la Constitution et les articles L. 2121-1 et suivants du Code de la défense. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Dès sa déclaration, les pouvoirs de maintien de l'ordre et de police exercés par l'autorité civile sont transférés à l'autorité militaire dans les conditions prévues par le Code de la défense. L'autorité civile conserve ses autres attributions.

c) L'état d'urgence

L'état d'urgence est un régime exceptionnel de police déclaré soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Sa déclaration permet **d'accroître les compétences de l'autorité civile et particulièrement le pouvoir de police des préfets et du ministre de l'Intérieur**. L'état d'urgence est régi par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Il est déclaré par décret en Conseil des ministres et sa prorogation au-delà de douze jours doit être autorisée par la loi. Les mesures prises dans ce cadre demeurent soumises au contrôle du juge administratif, notamment quant à leur nécessité et à leur proportionnalité au regard des circonstances

d) L'état d'urgence sanitaire

L'état d'urgence sanitaire a été instauré par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à la crise de la Covid-19. Il pouvait être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Ce régime conférait notamment au Premier ministre et au ministre chargé de la Santé des pouvoirs exceptionnels destinés à répondre à la crise sanitaire. Le préfet pouvait également être habilité à prendre

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

certaines mesures à l'échelle territoriale. Les dispositions spécifiques relatives à l'état d'urgence sanitaire ont cessé de s'appliquer le 1er août 2022.

Ce régime doit donc être présenté comme un dispositif historique et non comme un régime actuellement mobilisable sur le fondement des anciens articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du Code de la santé publique. Il ne faut pas le confondre avec les pouvoirs de police sanitaire qui demeurent prévus par le Code de la santé publique.

II. LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Différentes voies (A) et sources (B) de droit permettent au juge administratif de vérifier la conformité des actes administratifs aux droits et libertés fondamentaux. Au regard de la dualité des ordres de juridiction français, la protection des droits et libertés fondamentaux est répartie entre le juge administratif et le juge judiciaire. L'article 66 de la Constitution confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle, entendue dans son sens constitutionnel, notamment contre la détention arbitraire. Il ne réserve toutefois pas au juge judiciaire l'ensemble du contentieux des libertés fondamentales : le juge administratif exerce lui aussi un rôle essentiel, notamment par le recours pour excès de pouvoir et le référé-liberté. La justiciabilité de certains actes administratifs connaît par ailleurs des limites (C et D). .

A. LES RECOURS

Quatre recours jouent un rôle prépondérant en matière de défense des droits et libertés fondamentaux : le recours pour excès de pouvoir (1), le référé-suspension (2), le référé-liberté (3) et la question prioritaire de constitutionnalité (4).

La question prioritaire de constitutionnalité n'est toutefois pas un recours autonome contre un acte administratif : c'est un mécanisme incident de contrôle de la constitutionnalité d'une disposition législative applicable à un litige

1. Le recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est un **recours objectif** qui amène le juge à décider du sort de l'acte attaqué au regard de la seule légalité. En principe, il peut être introduit dans un délai de **deux mois** à compter de la publication (pour les actes réglementaires) ou de la notification de l'acte (pour les actes individuels). L'acte contesté doit être un acte administratif **faisant grief**. Le requérant doit avoir la **capacité d'ester en justice** et démontrer un **intérêt à agir**. Le délai de deux mois constitue le délai de droit commun, sous réserve des règles particulières applicables et des conditions dans lesquelles les délais de recours sont opposables. En particulier, l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification d'une décision individuelle peut empêcher le délai ordinaire de courir ; le destinataire ne peut toutefois pas, en principe, contester indéfiniment cette décision lorsqu'il en a eu connaissance (CE Ass 13 juillet 2016 Czabaj)

En cas d'annulation de l'acte, il **disparaît rétroactivement** de l'ordonnancement juridique. Cependant, dans la mesure où ce caractère rétroactif est susceptible d'affecter la sécurité juridique, le juge administratif a reconnu la possibilité de **moduler dans le temps** les effets d'une annulation et de décider que cette dernière ne prendra effet qu'à partir d'une certaine date. Cette possibilité de modulation dans le temps des effets de l'annulation a été consacrée par l'arrêt CE Ass 11 mai 2004 Association AC !. Elle demeure exceptionnelle et suppose que le juge mette en balance les conséquences d'une annulation rétroactive avec les exigences du principe de légalité.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

2. Le référé-suspension

Le référé-suspension permet d'obtenir d'un juge la **suspension provisoire de l'exécution** d'une décision administrative, même de rejet, faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, à condition que l'**urgence** le justifie et qu'il soit fait état d'un **moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision**. Le référé-suspension est prévu à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Il suppose donc un recours au fond contre la décision contestée. La suspension prend fin, au plus tard, lorsque le juge statue sur ce recours. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais. L'ordonnance rendue en référé-suspension est rendue en dernier ressort : elle n'est pas susceptible d'appel, mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dans les conditions applicables.

3. Le référé-liberté

Le référé-liberté, prévu à l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, permet au juge des référés, en cas d'urgence, d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Contrairement au référé-suspension, il n'exige pas qu'un recours au fond ait été introduit contre une décision administrative. L'atteinte peut notamment résulter d'un comportement ou d'une carence de l'administration. Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures

L'ordonnance rendue en référé-liberté est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de sa notification. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures (article L. 523-1 du Code de justice administrative). .

4. La question prioritaire de constitutionnalité

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative **porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit**, le Conseil d'État peut renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. Il faut simplement comprendre que, dans l'ordre judiciaire, le rôle de filtre équivalent appartient à la Cour de cassation.

Devant les juridictions relevant du Conseil d'État, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, **à peine d'irrecevabilité**, présenté dans un **écrit distinct et motivé**. La QPC peut être soulevée pour la première fois en appel et, dans les conditions prévues par les textes, devant le Conseil d'État. Le juge ne peut pas la relever d'office (articles 23-1 et 23-5 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958).

La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État. Il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; la question **n'est pas dépourvue** de caractère sérieux.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission, le Conseil d'État se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Le Conseil d'État exerce un second filtre avant un éventuel renvoi au Conseil constitutionnel. Il vérifie que 1/ la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2/ elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3/ la question est nouvelle ou présente un caractère

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

sérieux. Il faut donc distinguer les deux filtres : devant la juridiction du fond, la question doit ne pas être dépourvue de caractère sérieux ; devant le Conseil d'État, elle doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux (articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958)

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

B. LES SOURCES JURIDIQUES

Les principes et règles dont le respect s'impose à l'administration intègrent de nombreux droits et libertés fondamentaux. Ils peuvent être d'ordre interne (1) ou externe (2).

1. Les sources internes

En droit interne, les normes constitutionnelles occupent le sommet de la hiérarchie des normes. Le juge administratif est notamment amené à appliquer les droits et libertés issus du bloc de constitutionnalité. Celui-ci comprend la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Il comprend également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les autres principes et objectifs de valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel

Cela étant, **de nombreuses lois** ont été adoptées à partir de la fin des années 1970, lesquelles consacrent des droits subjectifs au profit des citoyens face à l'administration. Il en va ainsi par exemple de l'obligation de motiver certains actes administratifs résultant des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 – reprises aujourd'hui dans le **code des relations entre le public et l'administration** (art. L. 211-1 à L. 211-8 du CRPA). L'obligation de motivation n'est pas générale : l'article L. 211-2 du CRPA vise notamment certaines décisions administratives individuelles défavorables, parmi lesquelles les mesures de police, les sanctions et certains refus d'autorisation. Il faut donc vérifier, pour chaque décision, si un texte impose sa motivation.

Puis, les **principes généraux du droit**, règles non écrites, sont aussi une source traditionnelle des droits subjectifs des administrés. Il s'agit de principes consacrés par le juge administratif et applicables même sans texte. Ils ont une **valeur supra-décrétale et infra-législative**.

l s'agit notamment du respect des droits de la défense qui a été consacré par l'arrêt CE, sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier, puis reconnu comme principe général du droit par l'arrêt CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu ; du principe d'égalité devant le service public (CE, sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire) ; et du principe de sécurité juridique (CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres). .

2. Les sources externes

Les sources externes sont constituées par le **droit international général** et le **droit de l'Union européenne**. Or, la France est partie à de nombreux traités relatifs aux droits de l'homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, etc.).

L'inconventionnalité d'une disposition nationale, notamment d'une loi, peut être invoquée devant le juge administratif. Le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier la compatibilité d'une norme interne avec un engagement international applicable. Le Conseil d'État a longtemps refusé d'écarter une loi postérieure à un traité au motif qu'elle lui était contraire (CE, sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). Il a abandonné cette position dans l'arrêt CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, en acceptant de contrôler la compatibilité d'une loi avec un traité, même lorsque la loi est postérieure à celui-ci. Cette solution rejoint celle adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre. Lorsque la loi applicable au litige est incompatible avec un engagement international invocable, le juge administratif peut en écarter l'application. Il ne l'abroge pas et ne l'annule pas : la loi demeure dans l'ordonnancement juridique

La primauté du droit de l'Union européenne concerne le droit primaire, notamment les traités, ainsi que le droit dérivé, notamment les règlements et les directives, dans les conditions propres à chaque catégorie d'actes. Les règlements sont directement applicables. Les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre et

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

doivent, en principe, être transposées. Elles peuvent toutefois être invoquées directement par un justiciable à l'encontre de l'administration lorsque le délai de transposition est expiré et que leurs dispositions sont précises et inconditionnelles (CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux). Dans l'ordre juridique interne français, la Constitution conserve une place supérieure aux engagements internationaux : la supériorité reconnue aux traités par l'article 55 de la Constitution ne s'applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

C. **UN DOMAINE DE COMPÉTENCES LIMITÉ**

Aux termes de **l'article 66 de la Constitution**, « *l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi* ». L'article 66 réserve à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle au sens constitutionnel. Cette compétence doit être distinguée de celle du juge administratif, qui assure également la protection de nombreuses libertés fondamentales, notamment au moyen du référé-liberté.

La liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution s'entend aujourd'hui principalement de la protection contre les privations arbitraires de liberté, notamment les mesures de détention. Il ne faut pas la confondre avec l'ensemble des libertés fondamentales. La liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile ou encore la liberté du mariage bénéficient de protections constitutionnelles propres, sans relever indistinctement de la notion de liberté individuelle au sens de l'article 66. Cette distinction est essentielle pour déterminer si une atteinte commise par l'administration est susceptible de constituer une voie de fait

La voie de fait constitue une exception à la répartition ordinaire des compétences : lorsqu'elle est caractérisée, le juge judiciaire est compétent pour en ordonner la cessation ou la réparation. Cette compétence exceptionnelle doit toutefois être distinguée des pouvoirs dont dispose le juge administratif, notamment en référé, pour faire cesser certaines atteintes graves de l'administration aux libertés fondamentales. .

Selon le Tribunal des conflits, il y a **voie de fait** de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, dans deux hypothèses :

- Soit, l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ;
- Soit, l'administration a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative (**TC, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman.**).

La voie de fait exige donc la réunion de deux éléments : une irrégularité particulièrement grave tenant à l'action de l'administration et une atteinte à la liberté individuelle ou l'extinction d'un droit de propriété. Une simple atteinte au droit de propriété, même irrégulière, ne suffit pas à caractériser une voie de fait si elle n'entraîne pas l'extinction de ce droit. Depuis l'arrêt Bergoend, une atteinte à une liberté fondamentale autre que la liberté individuelle au sens de l'article 66 ne suffit plus à caractériser une voie de fait. De même, une atteinte irrégulière au droit de propriété qui n'entraîne pas son extinction ne constitue pas, à elle seule, une voie de fait. En dehors des hypothèses de voie de fait et des compétences attribuées au juge judiciaire par la Constitution ou par les textes, le juge administratif demeure en principe compétent pour connaître des atteintes aux libertés résultant de l'action administrative. Cette évolution renforce le rôle du juge administratif dans la protection des libertés et du droit de propriété. Le Tribunal des conflits a notamment confirmé sa compétence pour réparer les conséquences d'une emprise irrégulière n'entraînant pas l'extinction du droit de propriété (TC, 9 décembre 2013, M. et Mme Panizzon).

Il ne s'agit donc pas d'une concurrence générale entre les deux ordres de juridiction, mais d'une répartition des compétences, comportant des exceptions précisément délimitées

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

D. LES ACTES CONTRÔLÉS

Les actes de l'administration peuvent être **des contrats ou des actes unilatéraux**. En matière de droits et libertés fondamentaux, il convient de s'interroger plus précisément sur la possibilité de contester un acte administratif unilatéral qui serait contraire aux droits et libertés fondamentaux.

En principe, le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre un acte administratif faisant grief, c'est-à-dire produisant des effets juridiques susceptibles d'affecter la situation de son destinataire ou de tiers. Toutefois, le caractère décisoire de l'acte n'est plus une condition absolue de recevabilité du recours. Certains documents ou prises de position dépourvus de caractère obligatoire peuvent être contestés lorsqu'ils sont susceptibles de produire des effets notables sur les droits ou la situation des personnes concernées. Il convient donc de distinguer les actes de portée générale qui ne présentent pas nécessairement un caractère décisoire, mais peuvent être contestés sous certaines conditions (1), et les catégories d'actes dont la contestation directe demeure limitée ou exclue (2)

Mais il convient de remarquer que l'accès au prétoire du juge administratif ne cesse de s'étendre, permettant donc une soumission effective de l'administration au droit. Cette ouverture du prétoire se traduit par la réduction des catégories d'actes insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.

1. Les actes non décisoires

Les circulaires (a), les lignes directrices (b) et les actes de droit souple (c) constituent des instruments dont la portée juridique est variable. Ils ne sont pas tous dépourvus de caractère décisoire et leur contestabilité dépend notamment de leur contenu et de leurs effets. .

a) Circulaires

Les circulaires sont des actes de portée générale adressés par les chefs de service aux agents placés sous leur autorité à l'effet de leur indiquer la **manière d'interpréter et d'appliquer** les dispositions des lois et règlements. La jurisprudence a d'abord distingué les dispositions impératives des circulaires, susceptibles de recours pour excès de pouvoir, de leurs dispositions non impératives (CE, sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères). Cette distinction doit désormais être replacée dans le cadre plus large de l'arrêt CE, sect., 12 juin 2020, GISTI. Les circulaires et autres documents de portée générale émanant d'autorités publiques peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. Le caractère impératif demeure un indice important de la recevabilité du recours, mais il n'en constitue plus la condition exclusive

b) Lignes directrices

Les lignes directrices permettent à une autorité administrative de définir, pour l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, des critères destinés à orienter les décisions individuelles à venir. Elles se distinguent ainsi des circulaires qui ont principalement pour objet d'expliquer ou d'interpréter les textes applicables. Les lignes directrices ne doivent pas édicter de conditions nouvelles ni conduire l'autorité compétente à renoncer à l'examen particulier de chaque situation. L'administration peut s'en écarter pour un motif d'intérêt général ou en raison des particularités du cas examiné (CE sect 11 décembre 1970 Crédit foncier de France)

Les lignes directrices peuvent être invoquées, dans les conditions applicables, à l'occasion d'un recours contre une décision individuelle prise sur leur fondement. L'administré peut notamment soutenir que l'administration a méconnu les critères qu'elle s'était fixés ou qu'elle a omis d'examiner les particularités de sa situation. En outre, depuis l'arrêt CE, sect., 12 juin 2020, GISTI, les lignes directrices peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes concernées. Leur caractère impératif n'est pas exigé. Si un document présenté comme une ligne

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

directrice impose en réalité une règle nouvelle ou prive l'administration de tout pouvoir d'appréciation, sa légalité doit être examinée au regard de sa portée réelle et de la compétence de son auteur

c) Actes de droit souple

Ce qu'on entend par « droit souple » recouvre une **diversité d'actes de dénomination variable** qui ne se présentent pas formellement comme des actes décisoires (qui obligent, habilitent notamment) mais qui ne sont pas sans influence concrète sur leurs destinataires.

Le Conseil d'État a d'abord ouvert le recours pour excès de pouvoir contre certains actes de droit souple des autorités de régulation lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment économiques, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements de leurs destinataires (CE, Ass., 21 mars 2016, Fairvesta et Numericable). Il a ensuite étendu cette logique aux documents de portée générale émanant d'autorités publiques, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes ou interprétations du droit positif, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre (CE, sect., 12 juin 2020, GISTI). Les documents présentant un caractère impératif ou constituant des lignes directrices sont notamment susceptibles de produire de tels effets. Tout acte de droit souple n'est donc pas automatiquement contestable : le juge apprécie ses effets ou son influence.

2. Les « décisions » qui ne font pas grief

Il convient de distinguer les actes préparatoires (a), les mesures d'ordre intérieur (b) et les actes de gouvernement (c). Ces catégories ne relèvent pas toutes de la même logique : les actes de gouvernement, en particulier, ne sont pas de simples décisions dépourvues d'effets juridiques. .

a) Actes préparatoires

Les différentes étapes de l'édiction d'un acte administratif unilatéral se traduisent par la mise en œuvre de **mesures d'instruction et l'émission de prises de position successives de la part de l'autorité décisionnaire ou d'autres acteurs**.

Ces étapes peuvent prendre la forme de propositions, d'avis, de rapports, de délibérations préparatoires ou de demandes d'information. Leur qualification dépend toutefois de leur contenu et de leurs effets : une mise en demeure, par exemple, peut constituer une décision faisant grief lorsqu'elle impose par elle-même une obligation à son destinataire. . Les actes qui se bornent à préparer une décision ultérieure sont, en principe, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir autonome. Les irrégularités qui les affectent peuvent être invoquées, dans les conditions applicables, à l'occasion du recours dirigé contre la décision finale. Il faut toutefois vérifier si l'acte présenté comme préparatoire produit par lui-même des effets juridiques ou des effets notables justifiant sa contestation directe. La qualification ne dépend pas de sa seule dénomination

b) Mesures d'ordre intérieur

Les mesures d'ordre intérieur sont des mesures relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service dont les effets sont, en principe, jugés trop limités pour justifier un recours pour excès de pouvoir. Cette catégorie s'est toutefois considérablement réduite. Le juge tient compte notamment de la nature de la mesure, de la gravité de ses effets sur la situation de l'intéressé et de ses conséquences sur l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Les arrêts CE Ass 17 février 1995 dits Hardouin et Marie ont ainsi admis le recours contre certaines sanctions prononcées à l'encontre de militaires et de détenus. Cette évolution a été prolongée, en matière pénitentiaire, par les arrêts CE Ass 14 décembre 2007 Boussouar, Planchenault et Payet

c) Actes de gouvernement

Il s'agit des actes accomplis dans le cadre des fonctions gouvernementales.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Les actes de gouvernement constituent une catégorie jurisprudentielle d'actes qui échappent, par leur nature, au contrôle de légalité du juge administratif. Ils concernent principalement les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et les actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France. Cette exclusion ne signifie pas que tout acte présentant une dimension politique échappe au juge : il faut vérifier si l'acte relève effectivement de l'une de ces catégories

Il faut distinguer l'activité administrative du Gouvernement, en principe soumise au contrôle du juge, des actes de gouvernement, dont la légalité échappe à ce contrôle. .

Les actes de gouvernement peuvent être regroupés dans deux catégories :

1. Les actes intéressant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels : notamment la décision de recourir à l'article 16 de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale et certains actes relatifs à l'organisation d'un référendum. Il faut distinguer ces actes des décisions administratives prises pour leur mise en œuvre, qui ne bénéficient pas nécessairement de la même immunité juridictionnelle. ;

2. Les actes non détachables de la conduite des relations internationales : il s'agit notamment de certaines décisions prises dans les rapports de la France avec des États étrangers ou des organisations internationales, telles que des décisions relatives à la protection diplomatique. En revanche, les actes détachables de la conduite des relations internationales peuvent relever du contrôle du juge administratif.

Lorsqu'un acte est qualifié d'acte de gouvernement, le juge administratif ne peut pas en apprécier la légalité ni l'annuler. Cette immunité juridictionnelle ne signifie toutefois pas qu'aucune conséquence dommageable de l'acte ne puisse jamais donner lieu à indemnisation. Dans l'arrêt CE, Ass., 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, le Conseil d'État a admis que la responsabilité sans faute de l'État puisse, sous des conditions strictes, être engagée du fait de décisions non détachables de la conduite des relations internationales, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques. Cette responsabilité suppose notamment un préjudice spécial et d'une particulière gravité. Elle ne doit pas interférer avec la conduite de la politique extérieure et ne bénéficie pas, en principe, aux personnes dont la décision avait précisément pour objet de régir ou d'affecter la situation. Le juge peut donc, dans ce cadre limité, examiner une demande indemnitaire sans contrôler la légalité de l'acte de gouvernement.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite